

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4783/2549

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชาวละออเภสัช กับ
พวก

โจทก์

บริษัทมันทนพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด
กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 54

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยที่ 1 โดยกล่าวอ้างว่าการประดิษฐ์ที่มีส่วนประกอบของกาวเครือมีการเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่มาตั้งแต่ปี 2474 ก่อนวันที่จำเลยที่ 1 ขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จึงไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ นอกจากนี้การประดิษฐ์ดังกล่าวยังไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เพราะองค์ประกอบสมุนไพรรจากกาวเครือเป็นส่วนประกอบพื้นๆ ธรรมดาที่บุคคลอื่นและโจทก์ใช้หรือผลิตกันอยู่ทั่วไป ทั้งไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรืออื่นๆ ได้ คงถือเป็นเพียงการผสมสมุนไพรร จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ คำฟ้องดังกล่าวเป็นที่เข้าใจแล้วว่า สิทธิบัตรพิพาทไม่สมบูรณ์ เพราะเหตุใด การที่โจทก์ไม่ได้ระบุว่าเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวมีชื่อว่าอะไร เปิดเผยแพร่สำคัญอย่างไร เผยแพร่ที่ไหนอย่างไร บุคคลทั่วไปรวมทั้งโจทก์นำสมุนไพรร กาวเครือไปผสมกับสารอะไรในอัตราส่วนเท่าใด มีขั้นตอนการผลิตอย่างไร ล้วน

เป็นเพียงรายละเอียดซึ่งโจทก์สามารถนำสืบได้ในชั้นพิจารณา ฟ้องของโจทก์ไม่
เคลือบคลุม

โจทก์ประกอบธุรกิจจำหน่ายและผลิตยาและเครื่องสำอางซึ่งผลิตจากสมุนไพร
กาวาวเครือ ต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2542 จำเลยที่ 1 ประกาศใน
หนังสือพิมพ์ให้ผู้ผลิต ขาย มีไว้เพื่อขาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์จากกาวาวเครือที่มี
ลักษณะเช่นเดียวกัน หรือคล้ายกันกับองค์ประกอบสมุนไพรจากกาวาวเครือของ
จำเลยที่ 1 ยุติการกระทำและเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด จึงเป็นกรณีที่โจทก์
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกาวาวเครือเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ซึ่ง
หากสิทธิบัตรพิพาทมีผลสมบูรณ์ จำเลยที่ 1 ย่อมจะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการประดิษฐ์
ตามสิทธิบัตรดังกล่าวและมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นรวมทั้งโจทก์ในการประกอบการค้า
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกาวาวเครือได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณาจากข้อถือสิทธิที่
ระบุไว้ในสิทธิบัตรพิพาทเป็นสำคัญ โจทก์ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้เสียมีสิทธิฟ้องขอให้
เพิกถอนสิทธิบัตรได้ตาม พ.ร.บ.สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคสอง โดย
โจทก์ไม่ต้องบรรยายฟ้องในรายละเอียดว่า โจทก์ผลิตและจำหน่ายหรือมีไว้ซึ่งสินค้า
ดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด

ตำรายาหัวกาวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2474 ก่อน
ที่จำเลยที่ 1 จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งถือว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในตำรา
ดังกล่าวต่อสาธารณชนด้วยเพราะประชาชนทั่วไปย่อมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผย
ดังกล่าวได้โดยชอบแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการ
เผยแพร่ และจำนวนของเอกสารที่พิมพ์เผยแพร่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากร
ของประเทศ

สาระสำคัญของสิทธิบัตรพิพาทอยู่ที่ส่วนผสมของสมุนไพรจากกวาวเครือกับ ส่วนประกอบจากน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์ส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากนี้อาจจะมียูด้วยหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ได้ เมื่อดำรยาหัวกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรที่มีการพิมพ์เผยแพร่มาก่อนได้กล่าวถึงการนำกวาวเครือมาผสมกับนมสัตว์ บั้เป็นลูกกลอนใช้รับประทาน ซึ่งหากพิจารณาว่าใช้อัตราส่วนผสมอย่างละร้อยละ 50 ไม่ว่าจะมีส่วนประกอบอื่นในจำนวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมดังกล่าวหรือไม่ ก็จะมีลักษณะเดียวกับข้อถ้อยสิทธิของการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาท นั้นเอง การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทจึงไม่อาจนับเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ เพราะ มีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดไว้ก่อนแล้ว ทั้งลำพังการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ก็ไม่ได้ส่งผลให้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทเป็นการ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่และมีชั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น

โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่ประกอบธุรกิจจำหน่ายและผลิตยาทั้งแผนปัจจุบัน แผนโบราณ ยาจีน เครื่องสำอาง อาหารเสริมและบำรุงร่างกายที่มีสมุนไพรจากกวาวเครือเป็นองค์ประกอบ เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2542 จำเลยที่ 1 ได้ประกาศใน หนังสือพิมพ์ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรการประดิษฐ์ องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือตามสิทธิบัตรเลขที่ 8912 ให้ผู้ที่ผลิต ขาย มีไว้เพื่อขายและเสนอขาย ผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือที่มีลักษณะเช่นเดียวหรือคล้ายกันกับองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือตามสิทธิบัตรของจำเลยที่ 1 ยุติการกระทำดังกล่าว และให้เรียกคืน หรือจัดเก็บผลิตภัณฑ์อันถือเป็นการละเมิดสิทธิบัตรดังกล่าวออกจากท้องตลาดทันที โจทก์ทั้งสี่ตรวจพบว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ โดยอ้างว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ประดิษฐ์หรือผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์องค์ประกอบสมุนไพรจาก

กวาวเครือดังกล่าว และได้โอนสิทธิในการประดิษฐ์ รวมถึงสิทธิรับสิทธิบัตร และสิทธิอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้จำเลยที่ 1 ซึ่งการประดิษฐ์ที่จำเลยที่ 1 ขอรับสิทธิบัตรนั้นได้มีการเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่ตั้งแต่ประมาณปี 2474 แล้ว จึงมิใช่การประดิษฐ์ใหม่ โจทก์ทั้งสี่ได้นำสมุนไพรวงกวาวเครือไปเป็นส่วนผสมอันเป็นองค์ประกอบในการผลิตยาสมุนไพรวงซึ่งเป็นสินค้าและได้จำหน่ายในท้องตลาดมาเป็นเวลานาน การนำสมุนไพรวงกวาวเครือไปเป็นส่วนผสมอันเป็นองค์ประกอบในการผลิตยาสมุนไพรวงได้ตกเป็นสาธารณสมบัติบุคคลในสังคมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ ข้อเท็จจริงในสิทธิบัตรของจำเลยที่ 1 กลุ่มเครือ ไม่เฉพาะเจาะจงในการประดิษฐ์ไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ การประดิษฐ์ของจำเลยที่ 1 ไม่เป็นการประดิษฐ์มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือเรื่องอื่นๆ ได้ ส่วนประกอบหลักในการผลิต คือ กวาวเครือ เป็นพืชที่ทุกคนมีสิทธิใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือว่าเป็นลักษณะของยาหรือสิ่งผสมของยาที่มีพืชเป็นส่วนประกอบ ไม่ควรให้บุคคลใดผูกขาดถือสิทธิเอาเป็นของตนเอง ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 9 (1) การที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาออกสิทธิบัตรให้จำเลยที่ 1 ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นการละเมิดและโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสี่ ทำให้สาธารณชนทั่วไปและโจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหาย ขอให้พิพากษาว่า สิทธิบัตรตามคำขอเลขที่ 045463 สิทธิบัตรเลขที่ 8912 ที่ออกให้แก่จำเลยที่ 1 และที่ 2 ไม่สมบูรณ์และไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนสิทธิบัตรดังกล่าวและถือเอาคำพิพากษาแสดงต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเพิกถอนสิทธิบัตร เลขที่ 8912

จำเลยที่ 1 ให้การว่า โจทก์ทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ฟ้องของโจทก์ทั้งสี่เคลื่อนคลุม การประดิษฐ์ซึ่งจำเลยที่ 1 เป็นผู้ทรงสิทธิบัตรนั้นชอบด้วยกฎหมาย เพราะเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ มีชั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น และสามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม ก่อนวันยื่นขอรับสิทธิบัตรนั้น ยังไม่มีบุคคลใดคิดค้นหรือคิดทำขึ้นซึ่ง

ผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตร
พิพาท ไม่มีผู้ใดรวมทั้งโจทก์ทั้งสี่คัดค้านคำขอสิทธิบัตร โจทก์ทั้งสี่ใช้สิทธิโดยไม่
สุจริต ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ทั้งสี่ไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้ ฟ้องของโจทก์ทั้งสี่เคลื่อน
คลุม จำเลยที่ 2 เป็นผู้ประดิษฐ์องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือตามสิทธิบัตร
พิพาท และได้พัฒนากระบวนการผลิตขึ้นเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หลาในรูปแบบ คือ ทำ
เป็นชนิดผง น้ำอัดเม็ด แคปซูล และยาลูกกลอน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้ง่ายต่อการพก
พาและตามความเหมาะสมในการใช้ของผู้บริโภค การยื่นขอรับสิทธิบัตรพิพาทผ่าน
ขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมาย ไม่มีผู้ใดรวมทั้งโจทก์ทั้งสี่คัดค้าน สิทธิบัตรพิพาท
จึงชอบด้วยกฎหมายและเป็นการประดิษฐ์ที่ไม่ได้เป็นงานที่ปรากฏอยู่แล้วทั้งในและ
ต่างประเทศก่อนวันที่จำเลยที่ 1 ขอรับสิทธิบัตร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาว่า สิทธิบัตร
ตามคำขอเลขที่ 045463 เลขที่สิทธิบัตร 8912 ที่อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาออก
ให้จำเลยที่ 1 ไม่สมบูรณ์ ให้เพิกถอนเสีย โดยให้โจทก์ทั้งสี่ถือเอาคำพิพากษานี้แสดง
ต่ออธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อดำเนินการต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้ตกเป็น
พับ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า
"พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ทั้งสี่ประกอบการค้ายาและ
เครื่องสำอางซึ่งผลิตจากสมุนไพรกวาวเครือ เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2542
จำเลยที่ 1 ประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ผู้ผลิต ขาย มีไว้เพื่อขาย และเสนอขาย
ผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือที่มีลักษณะเช่นเดียวกันหรือคล้ายกันกับองค์ประกอบ

สมุนไพรรากกวาวเครือของจำเลยที่ 1 ยุติการกระทำและเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง ประการแรกว่า ฟ้องของโจทก์ทั้งสี่เคลือบคลุมหรือไม่ เห็นว่า คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยที่ 1 โดยกล่าวอ้างว่าการประดิษฐ์ที่มีส่วนประกอบของกวาวเครือดังกล่าวมีการเปิดเผยสาระสำคัญ หรือรายละเอียดในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ที่เผยแพร่มาตั้งแต่ปี 2474 ก่อนวันที่จำเลยที่ 1 ขอรับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ดังกล่าวจึงไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่ นอกจากนี้การประดิษฐ์ดังกล่าวยังไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้น เพราะองค์ประกอบสมุนไพรรากกวาวเครือเป็นส่วนประกอบพื้นๆ ธรรมดาที่บุคคลอื่นและโจทก์ทั้งสี่ใช้หรือผลิตกันอยู่ทั่วไป ทั้งไม่สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรืออื่นๆ ได้ เพราะไม่ใช่เรื่องการผลิตทางอุตสาหกรรม ไม่เป็นประโยชน์ทางอุตสาหกรรม คงถือเป็นเพียงการผสมสมุนไพรรากกวาวเครือ จึงไม่อาจขอรับสิทธิบัตรได้ คำบรรยายฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ดังกล่าวเป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มชัดแล้วว่า สิทธิบัตรพิพาทไม่สมบูรณ์เพราะเหตุใด ฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ไม่เคลือบคลุม ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่าคำฟ้องของโจทก์เคลือบคลุมหลายประการ เช่น โจทก์ทั้งสี่ไม่ได้ระบุว่าเอกสารหรือสิ่งพิมพ์ดังกล่าวมีชื่อว่าอะไรเปิดเผยสาระสำคัญอย่างไร เผยแพร่ที่ไหนอย่างไร บุคคลทั่วไปรวมทั้งโจทก์ทั้งสี่นำสมุนไพรรากกวาวเครือไปผสมกับสารอะไรในอัตราส่วนเท่าใด มีขั้นตอนการผลิตอย่างไร เป็นต้นนั้น ล้วนเป็นเพียงรายละเอียดซึ่งโจทก์ทั้งสี่สามารถนำเสนอได้ในชั้นพิจารณาคดี ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ไม่เคลือบคลุมจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการต่อมามีว่า โจทก์ทั้งสี่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในทำนองว่า โจทก์ทั้งสี่ไม่ใช่ผู้เสียหายที่แท้จริง จึงไม่มีอำนาจฟ้อง เห็นว่า โจทก์ทั้งสี่บรรยายฟ้องและนำเสนอว่า โจทก์ทั้งสี่

ประกอบธุรกิจจำหน่ายและผลิตยาและเครื่องสำอางซึ่งผลิตจากสมุนไพรกวาวเครือ ต่อมาเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2542 จำเลยที่ 1 ประกาศในหนังสือพิมพ์ให้ผู้ผลิต ขยาย มีไว้เพื่อขาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์จากกวาวเครือที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน หรือคล้ายกันกับองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือของจำเลยที่ 1 ยุติการกระทำ และเรียกคืนผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด จึงเป็นการบรรยายฟ้องและนำสืบแล้วว่าโจทก์ ทั้งสี่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรกวาวเครือเช่นเดียวกับจำเลยที่ 1 ซึ่งหากสิทธิบัตรพิพาทมีผลสมบูรณ์ จำเลยที่ 1 ย่อมจะมีสิทธิแต่ผู้เดียวในการ ประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรดังกล่าว และมีสิทธิห้ามบุคคลอื่นรวมทั้งโจทก์ทั้งสี่ในการ ประกอบการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกวาวเครือได้ ทั้งนี้ โดยพิจารณา จากข้อเท็จจริงที่ระบุไว้ในสิทธิบัตรพิพาทเป็นสำคัญ โจทก์ทั้งสี่ย่อมเป็นผู้มีส่วนได้ เสียในการฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรได้ตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 54 วรรคสอง โดยโจทก์ทั้งสี่ไม่ต้องบรรยายฟ้องในรายละเอียดว่า โจทก์ทั้งสี่ ผลิตและจำหน่ายหรือมีไว้ซึ่งสินค้าดังกล่าวตั้งแต่เมื่อใด สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกา ที่จำเลยทั้งสองอ้างมานั้น ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้ จึงไม่อาจนำมาเทียบเคียงได้ ที่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยมานั้นชอบแล้ว ศาล ฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นฟ้องด้วย อุทธรณ์ ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน อนึ่ง เมื่อคดีนี้โจทก์ทั้งสี่ต่างอ้างว่าตนเป็น ผู้มีส่วนได้เสีย และอาจฟ้องขอให้เพิกถอนสิทธิบัตรของจำเลยทั้งสองได้โดยลำพัง แล้ว อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ที่ 3 จึงไม่จำเป็นต้อง วินิจฉัยอีกเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

ปัญหาต้องวินิจฉัยประการต่อมาตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองมีว่า สิทธิบัตร พิพาทสมบูรณ์หรือไม่ โดยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในทำนองว่าสิทธิบัตรพิพาทเป็นการ ประดิษฐ์ขึ้นใหม่เป็นการประดิษฐ์ที่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นและเป็นการประดิษฐ์ที่ สามารถประยุกต์ในทางอุตสาหกรรมจึงเป็นสิทธิบัตรที่สมบูรณ์ เห็นว่า โจทก์ทั้งสี่มี

นายวัชพงษ์ พงษ์ปริบูรณ์ นางแจ่มจิตต์ เลาหวัณณ์ นายอภิญญา สันยาสี นางวรกานต์ ดวงจันทร์ นางเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และนายทรงพล จรรย์สืบศรี เบิกความยืนยันว่า ตำรายาหัวกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรดังกล่าวมีอยู่จริง และได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2474 ตามเอกสารหมายเลข 18 ส่วนจำเลยทั้งสองไม่ได้นำสืบหักล้างความมีอยู่ของตำรายาดังกล่าว คงนำสืบไม่รับรู้และอ้างว่าเพิ่งเห็นเอกสารดังกล่าวในภายหลัง รวมทั้งโต้แย้งว่าตำรายาดังกล่าวแตกต่างจากสิทธิบัตรพิพาทเท่านั้น พยานหลักฐานของโจทก์ทั้งสี่มีน้ำหนักดีกว่าและคดีเป็นอันรับฟังได้ว่าตำรายาหัวกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรมีอยู่จริง และได้ตีพิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2474 ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะยื่นคำขอรับสิทธิบัตร ทั้งถือว่าได้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ปรากฏในตำรายาดังกล่าวต่อสาธารณชนด้วย เพราะประชาชนทั่วไปย่อมสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยดังกล่าวโดยชอบแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพื้นที่ที่มีการเผยแพร่ และจำนวนของเอกสารที่ตีพิมพ์เผยแพร่เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์แต่อย่างใด

สำหรับข้อที่ว่า ข้อมูลในตำรับยาดังกล่าวเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทหรือไม่นั้นจะต้องพิจารณาเปรียบเทียบจากรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิทธิบัตรรวมตลอดถึงข้อถือสิทธิเป็นสำคัญ โดยจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในทำนองว่า การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 ประการ ตามข้อถือสิทธิข้อ 1 ส่วนความหมายของคำว่า "ร้อยละ 0" นั้นหมายความว่า สารดังกล่าวมีจำนวนน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสารอื่น มิใช่ว่าจะไม่มีเลยก็ได้ เห็นว่า สิทธิบัตรพิพาทระบุข้อที่แสดงถึงการประดิษฐ์ว่า องค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือ เมื่อพิจารณาบทสรุปการประดิษฐ์ระบุว่า "เปิดเผยถึงองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือชนิดขาว แดง ดำ ที่ประกอบด้วยส่วนประกอบน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์ และ/หรือส่วนประกอบจากสารอาหารรสหวาน และ/หรือส่วนประกอบจากพืชสมุนไพร และ/หรือส่วนประกอบอื่นๆ ชนิดใดชนิดหนึ่ง หรือ

หลายชนิด ร่วมกันเพื่อรักษาโรคบางชนิดและส่งเสริมสุขภาพ" สารสำคัญของสิทธิบัตรพิพาทจึงอยู่ที่ส่วนผสมของสมุนไพรจากกวาวเครือกับส่วนประกอบจากน้ำมัน และผลิตภัณฑ์จากนมสัตว์ ส่วนประกอบอื่นๆ นอกจากนี้อาจจะมีอยู่ด้วยหรือไม่ มากน้อยเพียงใดก็ได้ เพราะบทสรุปการประดิษฐ์ดังกล่าวใช้คำว่า "และ/หรือ" จึงแตกต่างจากข้ออุทธรณ์ของจำเลยทั้งสอง นอกจากนี้สิทธิบัตรพิพาทก็ไม่ได้แสดงให้เห็นปรากฏเลยว่า สารประกอบอื่นๆ เหล่านั้นมีความสำคัญ หรือจำเป็นในการประดิษฐ์นี้เช่นใด ประกอบกับเมื่อพิจารณาข้อถือสิทธิในสิทธิบัตรแล้ว จะพบว่าข้อถือสิทธิ ข้อ 2 ได้ระบุถึงปริมาณของส่วนประกอบต่างๆ โดยกวาวเครือชนิดขาว และ/หรือกวาวเครือชนิดแดง และ/หรือกวาวเครือชนิดดำจะมีปริมาณร้อยละ 10 ถึง 100 ของน้ำหนัก องค์ประกอบสมุนไพรที่ผลิตขึ้น น้ำมันและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันสัตว์ประเภทวัว ควาย แพะ มีปริมาณร้อยละ 0 ถึง 50 ของน้ำหนักองค์ประกอบสมุนไพรที่ผลิตขึ้น ส่วนสารประกอบอื่นๆ คือสารอาหารรสหวาน ส่วนประกอบจากสมุนไพร และสารประกอบเพื่อแต่งสี รส กลิ่น ลักษณะสารขึ้นรูป สารเพิ่มเนื้อ สารพาหะ มีปริมาณร้อยละ 0 ถึง 50 และ 0 ถึง 25 ของน้ำหนักองค์ประกอบสมุนไพรที่ผลิตขึ้นตามลำดับ และข้อถือสิทธิ ข้อ 3 ถึงข้อ 7 ก็มีข้อความในทำนองที่สามารถประกอบเพิ่มเติมด้วยสารอื่นได้อีก แสดงให้เห็นว่า การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทอาจจะไม่ได้ประกอบด้วยส่วนประกอบ 5 ประการ ดังที่ระบุไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งหากจำเลยทั้งสองโต้แย้งว่าสารประกอบอื่นๆ ตามข้อถือสิทธิ ข้อ 1 จำเป็นต้องมี แต่อยู่ในปริมาณที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนประกอบอื่นเช่นนี้ ก็ย่อมเป็นช่องทางให้บุคคลอื่นกล่าวอ้างถึงส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ได้ผลิตขึ้น ในทำนองนี้เช่นกัน ดังนี้ ข้อกล่าวอ้างของจำเลยทั้งสองดังกล่าวจึงไม่ได้แสดงให้เห็นเลยว่า การเติมสารประกอบอื่นๆ ในปริมาณที่น้อยมากเช่นนั้น ทำให้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทเกิดความแตกต่างจากตำรายาห้วกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรจนเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เช่นใดหนึ่ง การที่ข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรพิพาทได้ระบุไว้อย่างกว้าง เมื่อได้รับการยอมรับ

ให้จดทะเบียนสิทธิบัตรเช่นนี้ ย่อมจะเป็นการห้ามและกีดกันมิให้บุคคลอื่นคิดค้นประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ ที่จะมีลักษณะของส่วนผสมตามที่ระบุไว้ในข้อถือสิทธิได้ ซึ่งในทางกลับกัน การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทเป็นงานที่ไม่ปรากฏอยู่แล้วหรือไม่ ก็ย่อมจะต้องถูกพิจารณาเปรียบเทียบอย่างกว้างขวางเช่นเดียวกันและถือว่างานที่ปรากฏก่อนวันที่จำเลยที่ 1 ยื่นขอจดทะเบียนนั้นหากมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันข้อถือสิทธิตามสิทธิบัตรพิพาทแล้ว ก็จะทำให้การประดิษฐ์ของจำเลยที่ 1 ขาดความใหม่ได้ ทั้งนี้ การพิจารณาว่าการประดิษฐ์ใดเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่หรือไม่นั้น มิได้มีแต่เพียงวิธีการตามที่จำเลยทั้งสองนำสืบไม่เพราะวิธีตรวจสอบตามมาตรฐานสากลยังมีวิธีอื่นด้วย เช่น หลักเกณฑ์การทดสอบการละเมิดในภายหลัง (Post infringement test) เป็นต้น เมื่อตำรายาหัวกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรได้กล่าวถึงการนำกวาวเครือมาผสมกับนมสัตว์ ปั้นเป็นลูกกลอนใช้รับประทาน ซึ่งหากพิจารณาว่าใช้อัตราส่วนผสมอย่างละร้อยละ 50 ไม่ว่าจะเป็นสารประกอบอื่นในจำนวนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับส่วนผสมดังกล่าวข้างต้นหรือไม่ ก็จะมีลักษณะเดียวกับข้อถือสิทธิของการประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทนั่นเอง การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทจึงไม่อาจนับเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่ได้ เพราะมีการเปิดเผยสาระสำคัญหรือรายละเอียดไว้ก่อนแล้ว ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในทำนองที่ว่าตำรายาหัวกวาวเครือดังกล่าวไม่ได้การรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือการรับประทานยาตามตำรายาหัวกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรต้องมีพิธีกรรมอื่นประกอบนั้นไม่มีผลทำให้การพิจารณาความสมบูรณ์ของสิทธิบัตรเกี่ยวกับการประดิษฐ์ขึ้นใหม่เปลี่ยนแปลงไป สำหรับข้อเท็จจริงเรื่องสรรพคุณและลักษณะของการประดิษฐ์นั้น สิทธิบัตรของจำเลยที่ 1 ได้ระบุไว้ในบทสรุปการประดิษฐ์ว่าเพื่อรักษาโรคบางชนิดและส่งเสริมสุขภาพ ทั้งจำเลยที่ 2 ก็เบิกความยืนยันในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงไม่ต่างจากยาอายุวัฒนะตามตำรายาหัวกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทร และข้อถือสิทธิ ข้อ 8 ได้ระบุว่า "ขึ้นรูปตาม

ลักษณะองค์ประกอบสมุนไพรจากกวาวเครือที่ผลิตได้ และตามความเหมาะสมในการใช้ ซึ่งอาจเป็นลักษณะอัดเม็ด บั่นเป็นยาลูกกลอน ยาบรรจุในแคปซูล เป็นยาที่มีลักษณะเป็นน้ำ หรือเป็นยาที่มีลักษณะเหนียวตักได้" ดังนั้น การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทก็อาจมีลักษณะเป็นยาลูกกลอนด้วย หากให้มีเฉพาะแต่ลักษณะเป็นแคปซูล ดังที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ไม่ ทั้งล้าพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผลิตภัณฑ์เช่นนี้ หากได้ส่งผลให้การประดิษฐ์ตามสิทธิบัตรพิพาทเป็นการประดิษฐ์ขึ้นใหม่แต่อย่างใด ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างสิทธิบัตรพิพาทกับตำรายาหัวกวาวเครือของหลวงอนุสารสุนทรและเห็นว่าสิทธิบัตรพิพาทไม่ใช่การประดิษฐ์ขึ้นใหม่และไม่มีขั้นการประดิษฐ์ขึ้นจึงชอบแล้ว ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน กรณีไม่จำต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ข้ออื่นอีกต่อไปเพราะไม่ทำให้ผลคดีเปลี่ยนแปลง"

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้เป็นพับ.

(พรเพชร วิชิตชลชัย-สุวัฒน์ วรรณนະหทัย-พิชิต คำแฝง)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ